

제48회 상표법 2차 시험 해설

- 합격의 법학원 정상일 변리사 -

[A-1]

I. 설문(1)의 해결

1. 심결취소소송의 적법 여부 - 당사자 적격 및 소의 이익
--> 당사자로서 주체적 요건 만족, 패소한 자로서 소의 이익 긍정
2. 제7조 제1항 제11호
 - (1) 의의 및 취지 & 지역적 기준(국내)
 - (2) 상표 유사 판단 - 유사
 - (3) 상품 유사 판단 / 관련성 판단(Marzo 사건) - 비유사 & 관련성 X (타구공 등 vs 배낭 등)
 - (4) 사안의 적용 - 적용 부정
3. 제7조 제1항 제12호¹⁾
--> 적용 가능성 있음 (간략 검토 要)

II. 설문(2)의 해결

1. 취소심판의 청구이유 변경 가부 - 심결취소소송의 심리범위
 - (1) 학설 - 무제한설 / 제한설
 - (2) 판례 - 무제한설 / 결정계 심판 제외
 - (3) 사안의 검토 - 무제한설
2. 사안의 적용²⁾³⁾
 - (1) 지정상품 전부에 대한 불사용취소심판인 경우 - 무제한설에 따라 가능
 - (2) 지정상품 일부에 대한 불사용취소심판인 경우 - 청구취지 변경으로 허용 X (判)

1) 논점인지 여부가 문제에 명확히 드러나 있지는 않습니다. 그러나 을이 제기한 심결취소소송의 승소 가능성에 대하여 논하는 것이므로, 갑의 입장에서는 일본국 내에서의 사용을 근거로 법 제7조 제1항 제12호의 무효사유를 새롭게 주장하는 것이 가능합니다(무제한설). 따라서 갑의 상표가 일본 내에서 특정인의 상표로 알려져 있다면(부정한 목적은 있다고 볼 수 있음), 본호의 적용이 가능하다는 정도는 언급할 필요가 있다고 판단됩니다.

2) 사안은 특별한 언급이 없는 지정상품 전부에 대해 불사용취소심판을 청구한 것으로 보는 것이 타당하므로, 지정상품 일부에 대한 불사용취소심판청구의 경우는 간략히 언급하는 것으로 충분하다고 봅니다.

3) 한편, 경주빵 대법원 판례와 관련한 “제척기간 도과의 문제”는 무관합니다. 심결취소소송은 심결등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내에 제기할 수 있으며, 사안에서는 법 제73조 제1항 제2호의 제척기간인 취소사유가 소멸한 날로부터 3년(2010년 말)에 해당하기 전에 심결취소소송을 제기 & 취소사유 추가한 것이 명백합니다.

Ⅲ. 설문(3)의 해결

1. 제73조 제1항 제2호의 의의 및 취지
2. 유사 범위 사용 여부 - “배낭” 등과 “탁구라켓 케이스” 유사 판단
3. 대상상표의 적격 유무 - 인정
4. 고의 유무 - 인정
5. 혼동 가능성 - 인정
6. 사안의 적용 - 승소 가능성 긍정

[A-2]

Ⅰ. 문제되는 거절이유의 검토 - 제8조 제1항

Ⅱ. 상표권을 확보하기 위해 취할 수 있는 조치

1. 주체적 요건 - 상표관리인 선임
2. 조약우선권 주장 출원
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 효과
 - (3) 사안의 적용 - 판단시점 소급으로 거절이유 극복 가능
3. 정보제공, 이의신청 & 출원, 심사보류요청
 - (1) 의의 및 요건
 - (2) 정보제공이유 및 이의신청사유 사유 - 제23조 제1항 제3호(주논점), 제7조 제1항 제12호(간략 검토로 충분)
 - (3) 거절결정시 선원의 지위 (법 제8조 제3항)
 - (4) 사안의 적용 - 거절이유 극복 가능
4. 간과등록시 무효심판 및 취소심판 청구함으로써 등록 가능⁴⁾

4) 취소심판 청구 등의 조치는 문제 취지 및 배점을 고려할 때, 부수적인 논점인 것으로 보입니다. 자세하게(예컨대, 무효/취소심결의 효력, 출원시 제7조 제4항 제2호에 의해 제7조 제1항 제8호의 문제는 없다는 등의 논점) 검토할 필요는 없지만 간략히 언급할 필요는 있다고 판단됩니다.

[B-1]

I. 설문(1)의 해결

1. 을의 청바지 통신판매 행위가 X 등록서비스표권의 침해인지 여부

(1) 표장 유사

(2) 상표적 사용이 서비스표권의 권리범위에 속하는지 여부 - 동종성 판단

(3) 상표적 사용 여부 판단 - 상표적 사용

(4) 사안의 적용 - 침해

2. 오픈마켓 운영자의 책임 여부

(1) 직접침해 여부 - 직접침해 X (법 제50, 66조 / 제2조 제1항 제6호)

(2) 협의의 공동불법행위 책임 - 부정(判)

협의의 공동불법행위가 성립되기 위해서는 i) 객관적으로 피해자(권리자)에 대한 권리침해가 공동으로 행하여지고, ii) 그 행위가 손해발생에 공통의 원인이 되어야 하며, iii) 각 행위는 독립적으로 불법행위에 해당하여 하는데, 이러한 요건을 만족하지 않으므로 부정

(3) 부작위 방조에 의한 불법행위 책임 - 긍정(判)⁵⁾

1) i) 오픈마켓에서 권리 침해하는 행위가 실제로 발생하고, ii) 오픈마켓 운영자가 권리침해행위의 발생사실을 알았거나 알 수 있었다고 인정할 상당한 이유가 있으며, iii) 오픈마켓 운영자가 침해행위의 발생 내지 위험성을 방지하거나 제거할 수 있는 구체적인 수단을 가지고 있는 경우에는 침해행위를 방지할 구체적인 방지의무가 발생하며, 이를 위반한 경우에는 과실에 의한 방조책임 부담

2) 방지조치의무의 구체적 내용 - 을의 상품 등록 삭제, 적정한 운영 시스템 구축, 을의 인적사항 관리, X' 상표에 대한 거래 제한 등

II. 설문(2)의 해결

1. 등록 가능성 여부

(1) 법 제7조 제1항 제7호의 의의 및 취지

(2) 상품 vs 서비스업의 동종성 - 긍정

(3) 사안의 적용 - 현 상태로는 등록 가능성 없음

2. 등록받기 위한 조치⁶⁾

5) 오픈마켓 운영자의 방조에 의한 불법행위 책임을 부정한 판례(K2 사건)도 있으나, 해당 판례는 부정경쟁방지법 위반이 문제된 사건(특히, K2가 널리 알려진 표장인지 여부가 불명확한 사안)으로 상표권 침해가 문제되는 경우에는 요건 만족시 긍정 가능함.

- (1) 양수 - 법 제7조 제3항 단서
- (2) 무효심판청구 및 심사보류요청
- (3) 취소심결확정 후 재출원

III. 설문(3)의 해결

1. 법 제73조 제1항 제3호의 의의 및 취지 / 이해관계 여부
2. 갑의 사용을 등록서비스표의 사용으로 볼 수 있는지 여부
 - (1) 서비스표의 사용 개념 및 도소매업의 정의⁷⁾
 - (2) 사안의 적용 - 갑의 사용(OEM 방식에 의한 생산 및 수입행위)은 상표적 사용일지언정 서비스표의 사용으로 볼 수 없음. 나아가, 판매대리점을 통한 의류 판매는 “도소매업”에의 사용이기 보다는 판매점관리업을 한 것으로 볼 개연성이 큼. 따라서 등록서비스표를 사용한 것으로 볼 수 없음
3. 불사용의 정당한 이유 유무 - 없음
4. 사안의 적용 - 인용

[B-2]

I. 설문(1)의 해결

1. 법 제7조 제1항 제7호 (을의 등록상표와의 관계)
상표 비유사하여 적용 X
2. 법 제7조 제1항 제7호의2 (조합법인의 지표단과의 관계)
표장 유사 / 상품 동일하므로 적용
3. 법 제6조 제1항 제3, 4호 / 제7조 제1항 제11호⁸⁾
“만으로”아니므로 적용 X / “산지”에 대한 명확한 언급이 없음

II. 설문(2)의 해결

1. 조합법인의 지표단에 저촉되는지 여부

6) 사안에서, 등록 가능성 여부“만”을 묻고 있으므로, 등록받기 위한 조치는 출제자의 의도가 아닌 것으로 볼 수 있으나 배점(8점) 등을 고려할 때 등록받기 위한 조치를 간략히 검토하는 것도 득점 포인트가 될 것으로 조심스럽게 추측해봅니다.

7) 도소매업의 정의 등은 간략히 검토하여도 충분하나, 가장 중요한 것은 OEM 방식에 의해 생산된 제품에 상표를 부착한 것은 상표적 사용일뿐 서비스표적 사용은 아니며, 의류판매대리점을 통해 판매하는 행위는 도소매업에의 사용이 아니라는 점을 분명히 밝힐 필요가 있음.

8) 배점(6점) 및 문제에 주어진 사실관계를 통해 유추해 볼 때, 해당 논점은 간략히 언급하거나 생략하여도 무방할 것으로 판단됩니다.

- (1) 포장 유사 / 상품 동일(송이)⁹⁾
 - (2) 법 제51조 제2항의 적용
 - 1) 산지/현저한 지리적 명칭에 대해서도 효력 인정
 - 2) 법 제51조 제2항 제3호의 적용 - 정의규정 만족하게 사용할 경우
 - (3) 사안의 적용 - 저촉 X
2. 을의 상표권에 저촉되는지 여부
- (1) 포장 비유사
 - (2) 법 제51조 제1항 제2, 3호의 적용
 - (3) 사안의 적용 - 저촉 X

Ⅲ. 설문(3)의 해결

1. 을의 상표권의 효력

- (1) 적극적 효력 (제50조)
- (2) 소극적 효력 (제66조 제1항) / 제51조 제1항
상표 비유사 / 정당 권원 / 산지, 현저한 지리적 명칭에 대해 효력 인정
X --> 조합법인의 단체표장 사용에 대해 효력 인정 X

2. 조합법인의 단체표장권의 효력

- (1) 적극적 효력 (제50조)
- (2) 소극적 효력 (제66조 제2항) / 제51조 제2항 제4호
정당 권원 / 을의 상표 사용에 대해 효력 인정 X

3. 사안의 적용

양 권리자는 자신의 등록받은 표장을 자유롭게 사용 가능

※ 수험생 여러분, 고생 많으셨습니다. 모범답안이 출제자가 의도한 논점과 100% 일치할 수는 없으니 발표 때까지 마음 졸이지 마시고, 재충전의 시간을 가지시고 동차생분들은 잠깐의 휴식 후에 다시 공부에 매진하셨으면 합니다. 안녕히 계세요. - 정상일 드림 -

9) 2011년 개정 상표법 하에서 “동일한 것으로 인식할 수 있는 상품”에 대해서도 효력이 인정되나, 경과규정 및 배점 등을 고려할 때 언급하지 않아도 무방합니다.